

1502151-89.2021.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Angel Tomas Castroviejo

Comarca: Sertãozinho

Foro: Foro de Sertãozinho

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/03/2022

... milicianos para embasar a condenação em crimes de tráfico de drogas como o tratado nos autos:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sertãozinho

Foro de Sertãozinho

1ª Vara Criminal

Avenida Pedro Strini, 71, Sertãozinho-SP - cep 14160-260

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502151-89.2021.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502151-89.2021.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2256868/2021 - DISE-

DEL.SEC.SERTÃOZINHO, 20368997 - DISE- DEL.SEC.SERTÃOZINHO, 140/21/901 - DISE-

DEL.SEC.SERTÃOZINHO, 2256868 - DISE- DEL.SEC.SERTÃOZINHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIO MIRANDA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Angel Tomas Castroviejo

Vistos.

JOSÉ CRISOSTOMO FARIA DE OLIVEIRA e FABIO MIRANDA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c.c. o artigo 29 do Código Penal, porque, no dia 20 de setembro de 2021, por volta das 16h30min, na rua Benedita Alves Ferreira nº 30, Chácara de Recreio Pedregal (Vila Garcia), nesta cidade e comarca de Sertãozinho, guardavam e tinham em depósito, sem

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de mercancia e entrega a terceiros, 130 (cento e trinta) cápsulas de Cocaína pesando 178,79g (cento e setenta e oito gramas e setenta e nove decigramas) e 01 (uma) porção de Cocaína pesando 31,66g (trinta e um gramas e sessenta e seis decigramas), substância entorpecente capaz de determinar a dependência física e psíquica. Segundo a denúncia, policiais civis já haviam recebido a informação de que um endereço desconhecido na Vila Garcia estava sendo utilizado para armazenar drogas destinadas ao comércio ilícito. Após uma investigação preliminar, apurou-se que este sítio ficava ao lado de um campo de futebol no dito bairro, diante do que eles se dirigiram ao local. Lá, encontraram uma pequena construção na qual se encontravam os acusados, os quais, assim que notaram a presença dos policiais, tentaram empreender fuga e se embrenhar em uma mata próxima, mas acabaram sendo detidos. Na aludida construção, foram encontradas 130 (cento e trinta) cápsulas de Cocaína pesando 178,79g (cento e setenta e oito gramas e setenta e nove decigramas) e 01 (uma) porção de Cocaína pesando 31,66g (trinta e um gramas e sessenta e seis decigramas), uma balança de precisão, um saco contendo várias cápsulas tipo eppendorf vazias e R\$50,00 (cinquenta reais). Ainda pelos autos, o réu José informalmente admitiu que estava “enchendo os pinos” e guardando as drogas a pedido de um terceiro cuja identidade não revelou, em troca do que receberia R\$200,00 (duzentos reais). Ele e Fábio foram presos em flagrante delito.

Sendo a denúncia recebida em 30 de setembro de 2021 (fls. 147/148), os réus foram citados (José- fls. 205 e Fábio - fls. 237) e apresentaram defesa prévia (José - fls. 197/203 e Fábio - fls. 252/257).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, três testemunhas arroladas pela Defesa de José, sendo os réus interrogados ao final. Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a condenação de ambos os réus, nos termos da denúncia, com o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, mas não em seu patamar máximo, fixando-se regime fechado, sem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (v. mídia).

A Defesa do réu José requereu a absolvição, por insuficiência, sustentando, em síntese, que o local dos fatos não é de propriedade do réu, mas de uso comum, que o depoimento dos policiais é contraditório, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente requereu a fixação de penas mínimas, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, bem como o regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, concedendo-se o direito de recorrer em liberdade (v. mídia).

A Defesa do réu Fábio por sua vez, requereu a absolvição, por falta de provas. Subsidiariamente requereu a pena restritiva de direitos, e a aplicação do regime aberto, em cenário de pena corporal (fls. 297/302).

É o relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente em parte.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05/06), pelo boletim de ocorrência (fls. 13/15), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 18), pelas imagens fotográficas (fls. 28, 29, 30, 31 e 32), pelos exames químico-toxicológicos (FLS. 174/176), conclusivos por se tratar de Cocaína, pelo laudo pericial nº 323.084/2021 (fls. 189/192), e pelos depoimentos colhidos durante a instrução.

A autoria também é incontestada, mas apenas em relação ao réu José. Vejamos.

Os policiais civis João Reinaldo e André, tanto na fase policial quanto em Juízo, afirmaram que há dias haviam recebido informação de que num local na zona rural desta cidade, próximo à Vila Garcia, estariam sendo armazenadas drogas, que seriam vendidas naquele bairro. Após investigação preliminar, apuraram que tal local ficava próximo ao campo de futebol da Vila Garcia. Por esta razão, na data dos fatos, em diligência no local, com uso de viaturas descaracterizadas, em seguida a pé, chegaram ao local dos fatos, onde havia uma pequena construção, em que estavam

ambos os réus. Ao perceberem a presença dos policiais, tentaram correr e se embrenhar em uma mata ali próxima. Porém, foram alcançados e detidos. Voltando ao local onde estavam inicialmente, na construção já citada, foram encontrados as drogas, balança, cápsulas vazias e dinheiro. Indagados, José assumiu que estava de fato "enchendo os pinos" e guardando as drogas para um terceiro, de quem não quis declinar os dados, e ganharia R\$200,00 (duzentos reais) para tanto. Já Fábio negou que estivesse participando do delito, ou seja, associado ao corréu, alegando que estava no local para comprar Maconha, apesar de não haver tal droga no local e ele morar na Vila Áurea, local conhecido por ter vários pontos de venda de drogas e longe dali. Acrescentaram ainda em Juízo que somente os dois réus estavam no local (fls. 07/08 e mídia).

A testemunha Maria Valdete, arrolada pela Defesa de José, disse que mora no mesmo bairro do réu José, tendo conhecimento que ele cria porcos e galinha (v. mídia).

A testemunha Josmar, arrolado pela Defesa de José, disse que conhece o réu há mais de quinze anos e sabe que o réu trabalhava com a venda de animais (v. mídia).

A testemunha João Batista, arrolado pela Defesa de José, disse que o réu vive na Vila Garcia e cria porcos e galinhas (v. mídia).

O réu Fábio, interrogado na fase policial, disse que trabalha na Fundação Moreno, que já foi preso por furto e que, no momento, é apenas usuário de Maconha. Negou que seja traficante de drogas e que estivesse associado ao José para a prática de tal crime. Narrou que por ser usuário de Maconha, estava com José em busca de uma droga de boa qualidade, visto que onde mora só há Maconha de má qualidade. Aduziu que no momento da abordagem, estava sendo informado por José que ali não havia Maconha, diante disso, estava tentando saber de um lugar na Vila Garcia que tivesse a droga. Confessou que tentou fugir da abordagem, porém, não teve êxito. Viu o momento em que os policiais encontraram cápsulas vazias, uma balança e "pinos" com Cocaína (fls. 09). Em Juízo, disse que foi até o local dos fatos para pegar um animal que estava com o réu José, dada a ocupação deste último. Esclareceu que para comprar a Maconha, foi até um local na própria Vila, não com José, e mesmo assim não conseguiu comprar a droga, porque não estava disponível. Alegou que não correu dos policiais, mas José sim, pois os policiais chegaram disparando com arma de fogo. Aduziu que, durante a abordagem, ficou distante de José e que foram agredidos pelos policiais. Informou ter sido arrastado e sofrido agressões nos órgãos genitais. Quanto à declaração médica de fls. 40, disse que o médico o examinou superficialmente, enquanto ele ainda estava na traseira da viatura (v. mídia).

O réu José, interrogado na fase policial, permaneceu em silêncio (fls. 10). Em Juízo, negou a acusação. Disse que ia diariamente ao local para cuidar de seus animais, e na ocasião o corréu Fabio chegou para comprar um animal. Neste momento saíram vários policiais do mato, e porque assustado também saiu correndo, mas Fábio não correu. Disse que tentou fugir, com medo dos policiais quererem matá-lo, mas caiu e foi alcançado por eles. Foi torturado pelos policiais, por mais de 01 (uma) hora, ficou todo arrebitado, até confessar. Disse que os policiais ameaçaram Fábio com um cabo de enxada, além de proferir dizeres sobre o uso de um saco para torturá-los. Esclareceu que confessou por conta da tortura sofrida, mas que nunca trabalhou com drogas, sendo que vende apenas animais. Disse ainda que cria animais há muito tempo e todos sabem sobre seu ofício. Disse que alimenta os animais duas vezes ao dia, às 08:00 e às 15:00. Alegou que passaram pela UPA, mas nem saiu da viatura, alegando ser falsa a declaração médica juntada a fls. 41 (v. mídia).

Por sua vez, conforme dispõe o art. 52, inciso I, da Lei 11.343/06, deve-se levar em consideração, para classificação do delito, a natureza e a quantidade da substância apreendida, bem como as circunstâncias da prisão.

Diante das provas produzidas durante a instrução, é possível concluir que o acusado José era realmente o proprietário da droga apreendida e que se destinaria à comercialização.

Conforme narrado de forma uníssona pelos policiais civis João e André, após receberem informações sobre um local no qual estava havendo armazenamento de drogas, foram até o local e realizaram a abordagem de dois indivíduos que lá estavam. No local, os policiais encontraram drogas, balança, cápsulas vazias e a quantia apresentada nas fls. 16/17.

Ainda segundo os policiais, o próprio réu José confessou, informalmente, aos agentes de segurança que estava “enchendo os pinos” e guardando as drogas para um terceiro, de quem não quis declinar os dados, e ganharia R\$200,00 (duzentos reais) para tanto. Foram firmes os policiais ainda quando identificaram os réus como sendo as pessoas que foram vistas junto dos entorpecentes e que tentaram fugir, mas foram perseguidos e detidos.

O réu Fábio, quando interrogado na fase policial, disse que estava tentando comprar Maconha de José quando foram detidos, já em Juízo mudou sua versão, dizendo que estava na verdade comprando um porco do corréu.

O réu José também negou as acusações, alegando que foi forçado a confessar, e que na verdade estava no local apenas para cuidar de seus animais.

Conforme se verifica, as versões apresentadas pelos acusados são conflitantes, esmaecidas de verossimilhança. Inicialmente, o acusado Fábio disse ter ido buscar drogas com o corréu José Crisóstomo, a indicar que o local é conhecido de usuários e traficantes como ponto de traficância ou armazenamento de substâncias ilícitas. Já José, inicialmente, assumiu estar envasando drogas mediante pagamento, a mando de terceira pessoa, sem declinar que seria seu pagador.

De outra nuance, os interrogandos não foram hábeis em desconstruir os relatos policiais, firmes e coesos, lastreados em apreensão de significativas quantidades de drogas, bem como objetos comumente usados para envase e venda das substâncias ilícitas.

Por outro lado, ainda que a droga apreendida estivesse apenas sendo armazenada para terceira pessoa, é certo que tal conduta também configura o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, que é de múltiplas condutas.

Observe-se que a credibilidade dos depoimentos dos policiais ouvidos na fase policial e em Juízo ainda vem corroborada pela prova documental e pericial já citadas, sendo certo que não existe qualquer indicativo nos autos de que tivessem a intenção de prejudicar os acusados. Neste sentido:

“O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos.” (STF – HC nº 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

De resto, é de maciça jurisprudência, prolatada inclusive pelas Cortes Superiores quanto a suficiência da prova testemunhal consistente em depoimentos de milicianos para embasar a condenação em crimes de tráfico de drogas como o tratado nos autos:

“HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo produzido nos autos, não se coaduna com a via estreita do writ. Precedentes. 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada.” (STJ Min. Laurita Vaz 5ª Turma HC nº Relator: Salles Abreu Apelação nº 0034020-74.2011.8.26.0602 Voto nº: 115516/SP 03/02/2009).

Assim é que não se contesta a validade dos dois depoimentos acima delineados, que constituem prova é perfeitamente aceitável.

A propósito, já se decidiu no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TRÁFICO – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito – Coeso testemunho dos policiais militares - Validade – Ausência de dúvida que justifica o édito condenatório – Desclassificação para o

crime do art. 28 da Lei de Drogas - Tráfico caracterizado - Condenação mantida - PENA - redutor no patamar máximo - necessidade - Possibilidade de substituição da corporal por restritivas de direitos e fixação do regime aberto - Recurso parcialmente provido. (TJSP - Apelação 0000529-77.2015.8.26.0621 - Relator(a) Desembargador(a) Newton Neves - d.j. 20.02.2018).

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. REGIME FECHADO. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. (TJSP - Apelação Criminal n. 0025717-46.2012.8.26.0114 - Relator(a) Desembargador(a) Airton Vieira - d.j. 05.12.2017).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - PROVA ORAL INCRIMINADORA - A JURISPRUDÊNCIA É PACÍFICA AO RECONHECER A VALIDADE DO TESTEMUNHO DOS POLICIAIS MILITARES - O ORDENAMENTO PÁTRIO CONSAGROU O CRITÉRIO DO RECONHECIMENTO JUDICIAL EM RELAÇÃO AO CRIME DO PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO E NÃO O DA QUANTIFICAÇÃO LEGAL PARA A CARACTERIZAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS - DESTINAÇÃO COMERCIAL DOS ENTORPECENTES APREENHIDOS DELINEADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA PENAL INALTERADA - REGÊNCIA PRISIONAL MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP - APELAÇÃO nº 0000219-84.2016.8.26.0573 - Relator(a) Desembargador(a) Euvaldo Chaib - d.j. 14.11.2017).

"PROVA - Testemunha - Policial - Validade - Inexistindo indícios de que policiais tivessem interesse em acusar gratuitamente e de maneira falsa o réu, ausentes, ainda, elementos que indiquem perseguição policial, de afastar-se eventual suspeita sobre o depoimento ofertado, considerando-se, também, que na condição de funcionários públicos que são, gozam de fé pública e seus depoimentos elevem ser aceitos como verdadeiros máxime quando encontram eco nos demais elementos colecionados nos autos - Recurso parcialmente provido". (Apelação Criminal n. 993.07.113380-9 - Ibitinga - 14a Câmara de Direito Criminal - Relator: Alfredo Fanucchi - 14.08.08 - V.U. - Voto n. 8007).

"PROVA - Depoimento policial - Valor - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - O depoimento de policiais, que no cumprimento de sua missão atuam na repressão penal, é tão válido como qualquer outro testemunho - A circunstância de ser policial a testemunha, não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra - Precedentes do Col. Supremo Tribunal Federal - Recurso improvido neste aspecto" (Apelação Criminal n. 993.08.043553-7 - São Paulo - 16a Câmara de Direito Criminal - Relator: Newton Neves - 09.09.08 - V.U. - Voto n. 5652).

"PROVA - Depoimento de policial - Validade - Testemunhos prestados por policiais que procederam à prisão do acusado - Eficiência - Hipóteses de suspeição e impedimento com previsão legal exaustiva - Ocorrência - Apelação provida parcialmente" (Apelação Criminal n. 1.002.701-3/7 - São Paulo - 9a Câmara do 5o Grupo da Seção Criminal - Relator: René Nunes - 28.02.07 - M.V. - Voto n. 10.200). Assim, considerando que a significativa quantidade e variedade de droga encontrada é superior ao que normalmente encontrada com meros usuários, bem como o fato de ter sido encontrado também no local diversos apetrechos comumente utilizados para o preparo da droga em porções, como balança de precisão e eppendorfs, sendo possível, dessa forma, presumir que o acusado José realmente praticava com regularidade o tráfico no local, onde também criava animais para venda, da forma como dito pelas testemunhas arroladas pela Defesa.

No tocante às alegações dos réus de que o flagrante foi forjado, e que ainda foram bastante agredidos, durante a abordagem, pelos policiais, suas declarações são inverossímeis e encontram-se isoladas nos autos. Destaco, a propósito, que há nos autos laudos subscrito por médico atestando que os réus não apresentavam sinais de agressão física externa como equimoses, hematomas, escoriações pelo corpo ou deformidades ósseas, não havendo qualquer motivo nos autos para se suspeitar destas declarações.

Embora tenham mudado as versões em Juízo, com alegações de uso de tortura para obter confissão por parte do acusado José, não há nada nos autos que indique o uso deste método nefasto e condenável, supostamente utilizado pelos agentes de segurança. Durante toda a fase inquisitiva e na marcha processual, os acusados sequer aventaram a ocorrência de tortura como forma de obter confissão, guardando tal alegação para uso em interrogatório judicial, sem trazer elementos indiciários do fato.

Por fim, em relação ao réu Fábio, reputo que a prova é frágil e não sustenta um decreto condenatório. Além de ter declarado que estava no local apenas comprar droga, seja de José ou de outra pessoa, as testemunhas arroladas pela Defesa de José confirmaram que apenas o réu José é quem utiliza a área para cuidar de seus animais, sendo certo ainda que os policiais confirmaram também que apenas José confessou informalmente a posse da droga. Assim, reputo que a prova dos autos, quanto ao réu Fábio, não é conclusiva e firme para se afirmar que estivesse praticando o tráfico em conluio com José, ou fosse coproprietário da droga apreendida.

A acusação formulada na denúncia, portanto, em relação ao réu José, foi devidamente confirmada pelas provas produzidas durante a instrução criminal, não se podendo alegar insuficiência probatória.

Demonstrada, pois, a materialidade e indubitosa a autoria, tem-se que é de rigor a condenação do réu José como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, passando-se à dosimetria da pena.

Na primeira fase, fixo a pena base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o réu José é confesso, porém tal circunstância atenuante não tem o condão de fazer com que a pena seja reduzida aquém do mínimo (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, inicialmente observo que a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, notadamente a fração a ser aplicada, deve observar as diretrizes previstas no art. 42 da mesma lei, que impõe seja considerado, na fixação das penas, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social dos agentes.

Neste sentido:

"O art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base quanto na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da nova Lei de Tóxicos. 3. Não se trata de violação ao princípio do non bis in idem, mas apenas da utilização da mesma regra em finalidades e momentos distintos. Com efeito, na primeira etapa da dosimetria, os critérios do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 servem para fundamentar a pena-base, enquanto no último momento do sistema trifásico os mesmos parâmetros serão utilizados para se estabelecer a fração de redução a ser aplicada em razão da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei Antitóxicos. (...) 6. Ordem denegada." (STJ - HC n.º 165800/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Dje. 15.03.2012).

Assim, levando em conta que o réu José é primário e não ostenta maus antecedentes, também não havendo provas de que integre organização criminosa, reduzo as penas acima indicadas em metade, totalizando de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Neste contexto, importa tecer breve consideração sobre o critério para escolha da fração de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 do SISNAD. O caso concreto apresenta distinção, considerando a quantidade de drogas apreendidas em poder dos acusados e sua espécie - cocaína -, cujo potencial de danos à saúde de seus usuários é conhecida, tratando-se de substância causadora de dependência física e psíquica, podendo ocasionar a morte com um único uso, já que, em certos casos, de acordo com a tolerância do indivíduo, o consumo de 1,2g é suficiente para ocasionar uma overdose. No caso em apreço, foram localizadas mais de 200 g da droga conhecida como cocaína, restando indubitosa a concretização do perigo concreto à saúde pública. Nesta senda, incabível a aplicação da fração máxima de redução da pena.

Este é o entendimento adequado e acolhido pelo Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO PERMITE AFERIR A DEDICAÇÃO DOS ACUSADOS À ATIVIDADE CRIMINOSA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO FIXADA EM 1/5 (UM QUINTO) EM RAZÃO DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. MODULAÇÃO ADEQUADA. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO." (AgRg no HC 563.849/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 03/03/2022)

Não havendo outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar ou mesmo causas de aumento ou diminuição da pena, torno definitiva a pena fixada. O valor do dia-multa é fixado no mínimo de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado a partir da mesma data.

Relativamente ao regime prisional e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, cumpre observar o que foi decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do HC 97.256/RS.

Em referido julgado o Supremo Tribunal Federal concedeu parcialmente a ordem pleiteada e decidiu pelo cabimento de pena alternativa, removendo o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, julgado inconstitucional nesta parte, assim como da expressão análoga "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal.

Assim foi redigida a ementa do julgado:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 44 DA LEI 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA CF/88). ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da personalização da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em três momentos individuados e complementares: o legislativo, o judicial e o executivo. Logo, a lei comum não tem a força de subtrair do juiz sentenciante o poder-dever de impor ao delinqüente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo. Implicando essa ponderação em concreto a opção jurídico-positiva pela prevalência do razoável sobre o racional; ditada pelo permanente esforço do julgador para conciliar segurança jurídica e justiça material.

2. No momento sentencial da dosimetria da pena, o juiz sentenciante se movimenta com ineliminável discricionariedade entre aplicar a pena de privação ou de restrição da liberdade do condenado e uma outra que já não tenha por objeto esse bem jurídico maior da liberdade física do sentenciado. Pelo que é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória.

3. As penas restritivas de direitos são, em essência, uma alternativa aos efeitos certamente traumáticos, estigmatizantes e onerosos do cárcere. Não é à toa que todas elas são comumente chamadas de penas alternativas, pois essa é mesmo a sua natureza: constituir-se num substitutivo ao encarceramento e suas seqüelas. E o fato é que a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal. As demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero.

4. No plano dos tratados e convenções internacionais, aprovados e promulgados pelo Estado brasileiro, é conferido tratamento diferenciado ao tráfico ilícito de entorpecentes que se caracterize pelo seu menor potencial ofensivo. Tratamento diferenciado, esse, para possibilitar alternativas ao encarceramento. É o caso da

Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, incorporada ao direito interno pelo Decreto 154, de 26 de junho de 1991. Norma supralegal de hierarquia intermediária, portanto, que autoriza cada Estado soberano a adotar norma comum interna que viabilize a aplicação da pena substitutiva (a restritiva de direitos) no aludido crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

5. Ordem parcialmente concedida tão-somente para remover o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, assim como da expressão análoga "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal. Declaração incidental de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da proibição de substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos; determinando-se ao Juízo da execução penal que faça a avaliação das condições objetivas e subjetivas da convalidação em causa, na concreta situação do paciente.

(HC 97256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2010, DJe-247 DIVULG 15-12-2010 PUBLIC 16-12-2010 EMENT VOL-02452-01 PP-00113).

Seguindo a determinação do Colendo Supremo Tribunal, cuja decisão, por força da Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, com fundamento no art. 52, X, da Constituição Federal, passou a ter efeito "erga omnes", cumpre avaliar as condições objetivas e subjetivas para a fixação do regime prisional e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Para tanto, o próprio Supremo Tribunal Federal observou neste julgado que cabe ao juiz sentenciante "o poder-dever de impor ao delinquente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo". Ponderou também que "a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal; as demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero".

Assim sendo, analisando o caso concreto, além de a penalidade imposta impedir, reputo não socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, para reprovação e prevenção do crime, bem como conveniente e adequada a fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena imposta, nos termos do artigo 33, § 3.º, do Código Penal.

Inicialmente observo que o tráfico de drogas é de gravidade social elevada, notadamente em razão de suas sérias consequências, tão nefasto à saúde pública e à sociedade. Isso porque arrebatava vidas do seio familiar, causa danos à saúde pública, e afeta a psicologia de toda a sociedade. É o consumo de psicotrópicos que corrompe o indivíduo socialmente sã, aliciando-o para o cometimento de delitos contra o patrimônio, delitos domésticos, em evolução criminosa até culminar com crimes contra o bem constitucional vida, bem como responsável pela desestruturação de muitas famílias.

Não bastasse, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á em observância dos critérios previstos no artigo 59 deste Código e, especificamente em relação aos crimes previstos na Lei de Drogas, deve-se ter em conta ainda as regras previstas nos artigos 42 e 43 da Lei 11.343/06, que determinam sejam consideradas, na fixação das penas, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

A propósito, reitero que o acusado José estava na posse de significativa quantidade da droga cocaína, além de diversos apetrechos comumente utilizados para o preparo da droga em porções, como balança de precisão e eppendorfs vazios, sendo possível, dessa forma, presumir que realmente praticava com regularidade o tráfico, a justificar ser duramente apenado.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu JOSÉ CRISOSTOMO FARIA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, à pena de

02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor mínimo, como incursos no art. 33, caput, c.c. § 4º, da Lei 11.343/06, e ABSOLVER o réu FABIO MIRANDA, qualificado nos autos, da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Declaro a perda, em favor da União, do dinheiro apreendido, porque não comprovada sua origem lícita, presumindo que fosse proveniente da atividade ilícita do tráfico.

Faculto o recurso em liberdade, expedindo-se alvará de soltura.

Em face da condenação, o réu José arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei Estadual 11608/03, ficando sobrestada a cobrança, caso seja beneficiário da assistência judiciária gratuita.

P.R.I.C.

Sertãozinho, 11 de março de 2022.

Angel Tomas Castroviejo
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA